

共犯の従属性に関する次の【見解】に従って後記1から5までの各【記述】を検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

【見 解】

共犯が成立するためには、正犯の行為が構成要件に該当し、違法性を具備することを要する。

【記 述】

1. 甲が強盗犯人Aの妻乙を唆してAを蔵匿させた場合、甲には犯人蔵匿罪の教唆犯は成立し得ない。
2. 甲が刑法第41条の刑事未成年者に当たる乙を唆して窃盗を行わせた場合、甲には窃盗罪の教唆犯は成立し得ない。
3. 甲が乙にAが一人で居住する家屋に侵入するよう唆したところ、乙がAの承諾を得て平穩にその家屋に立ち入った場合、甲には住居侵入罪の教唆犯は成立し得ない。
4. 甲が乙を唆して私文書を偽造させたが、乙に行使の目的がなかった場合、甲には私文書偽造罪の教唆犯は成立し得ない。
5. 甲が乙に偽証するよう唆したところ、乙が証人として法律により宣誓した上、虚偽の陳述をしたが、証人尋問手続が終了した後、判決言渡し前に自白した場合、甲には偽証罪の教唆犯は成立し得ない。

No148

共通H30-13

共犯の従属性

正解

3、4 (順不同)

正答率

85%

要素従属性とは、正犯者の行為が犯罪成立要件（構成要件、違法性、有责性、処罰条件）のどの部分まで完成していれば、共犯として処罰し得るのかという問題である。この点、誇張従属性説は、構成要件、違法性、責任、処罰条件の全てを要求する見解である。また、極端従属性説は、構成要件、違法性、責任までを要求する見解である。さらに、制限従属性説は、構成要件、違法性までを要求する見解である。加えて、最小限従属性説は、構成要件のみ要求する見解である。

設問の【見解】は、上記見解のうち、制限従属性説に当たる。

1 誤っている

甲は強盗犯人Aの妻乙を唆してAを蔵匿させているところ、犯人蔵匿等罪（103条）には「犯人……の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる」旨の特例（105条）が存在する。本記述では、犯人の妻乙には、犯人蔵匿罪の構成要件該当性・違法性・有责性が認められる（犯人蔵匿罪が成立する）が、その刑が免除されることがある。よって、【見解】に従えば、甲には犯人蔵匿罪の教唆罪が成立し得る。

2 誤っている

41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定し、「罰しない」とは、14歳未満の者には一律に責任能力がないとされ、責任が阻却されるため犯罪が成立せず罰せられないということである。本記述では、刑事未成年者である乙には、有责性は認められないものの窃盗罪の構成要件該当性・違法性が認められる。よって、【見解】に従えば、甲には窃盗罪の教唆犯が成立し得る。

3 正しい

住居侵入罪の「侵入」とは、平穩説からは住居の平穩を害する態様による立入りを、住居権説からは住居権者の意思に反する立入りをいう。乙はAの承諾を得て平穩にAの家屋に立ち入っている。したがって、乙の立入り行為は住居侵入罪の「侵入」に当たらず、乙には住居侵入罪の構成要件該当性が認められない。よって、【見解】に従えば、甲には住居侵入罪の教唆犯は成立し得ない。

4 正しい

行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書……を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する（159条1項）。「行使」とは、偽造文書を真正な文書として使用することをいい、「行使の目的」は、法益侵害結果を主観的要素の形で取り込む主観的構成要件要素又は主観的違法要素と呼ばれる構成要件要素と解されている。本記述では、行使の目的がない乙には私文書偽造罪の構成要件該当性が認められない。よって、【見解】に従えば、甲には私文書偽造罪の教唆犯は成立し得ない。

5 誤っている

170条は、「前条〔注：偽証〕の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前……に自白したときは、その刑を減輕し、又は免除することができる」と規定している。本記述では、乙には偽証罪の構成要件該当性・違法性・有责性が認められる（偽証罪が成立する）が、その刑を減免されることがある。よって、【見解】に従えば、甲には偽証罪の教唆犯が成立し得る。

以上により、正しい記述は3と4であり、したがって、正解は肢3と肢4（順不同）となる。